

1504371-59.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... que as drogas eram minhas e se prestavam ao tráfico. As drogas que estavam com a Bruna fui eu que dei, porque ela é minha mulher. Já fui condenado por tráfico e não conhecia os policiais.

Já a ré BRUNA, declarou na fase inquisitiva que não sabia a quantidade de drogas que Gabriel transportava; que as drogas encontradas em seu poder foram adquiridas através do seu marido, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504371-59.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504371-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050468/2022 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 23167312 - 02º

DELEGACIA DA DISE - DENARC, AK6645-1/2022 - 02º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PINHEIRO DO AMARAL e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 323.22

VISTOS.

GABRIEL PINHEIRO DO AMARAL e BRUNA FERNANDA PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta que no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 14:00 horas, na rua Guaianases, 53, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de propósitos, traziam com eles,

e transportavam, para consume de terceiros, cerca de 108,6 gramas de Cannabis sativa L e 4,3 gramas de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 125.

Defesa preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu GABRIEL nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime. Com relação a ré BRUNA, postulou pela desclassificação para o crime de uso.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição da ré pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de uso, aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33, com pena mínima e regime mais brando.

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa veio bem comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, dando conta dos 07 invólucros de cocaína, 55 invólucros de maconha, além da quantia de R\$ 335,00, localizados e apreendidos em poder dos réus.

Em complementação, o Exame Químico Toxicológico de fls. 112/114, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahidrocannabinol e cocaína.

A autoria, contudo, como bem colocado pelas partes, somente restou bem comprovada com relação ao réu GABRIEL.

E isso porque, com relação ao réu GABRIEL, os argumentos da Douta Defensoria Pública, não arredaram os fortes indícios e provas diretas que derivaram contra ele, em especial, pelos laudos periciais, testemunhas inquiridas e declaração do próprio acusado, que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu GABRIEL confessou que as drogas encontradas em seu poder eram para uso e também para a traficância; que Bruna é sua esposa e não trafica drogas, fls. 06. Em juízo declarou que no dia dos fatos eu estava no local, eu tinha uma droga, quando os policiais chegaram. Eu tinha comprado as drogas para meu consumo, mas acabei com intuito de vender para ajudar a pagar as contas.

Confesso que as drogas eram minhas e se prestavam ao tráfico. As drogas que estavam com a Bruna fui eu que dei, porque ela é minha mulher. Já fui condenado por tráfico e não conhecia os policiais.

Já a ré BRUNA, declarou na fase inquisitiva que não sabia a quantidade de drogas que Gabriel transportava; que as drogas encontradas em seu poder foram adquiridas através do seu marido, pois é usuária de drogas; que está grávida, fls. 07. Em juízo declarou foi numa segunda feira. Deixei meus filhos no colégio, eu tenho um carrinho de lanche. Gabriel estava lá e me chamou para conversar, e me deu quatro parangas de maconha, porque sou usuária. Nisso os policiais vieram e nos abordaram. O restante das drogas era dele. Não estou grávida e sou ex companheira do Gabriel. Nunca fui presa antes e não conhecia os guardas municipais.

É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo o édito condenatório. Mas é certo também que quando vem acompanhada dos demais elementos probatórios como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

Desta forma, o tráfico praticado pelo acusado restou incontestado, enquanto a desclassificação da conduta da ré para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos, diante das provas produzidas é também de rigor.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, as drogas apreendidas em poder do réu GABRIEL, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que dificilmente usuários de drogas permanecem perambulando pela cidade com tamanha quantidade de drogas. Tal risco somente é assumido por traficantes, no afã de ganharem dinheiro fácil.

Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, o local conhecido como ponto de venda de drogas, a grande quantidade de drogas encontradas, a forma como

estavam acondicionadas, em papelotes distintos, prontos para a venda individual, a confissão dos réus, somado ao relato firme e seguro por parte dos agentes civis, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é que os guardas civis metropolitanos responsáveis pela prisão, Milton Cunha Matia e Ivan Nunes da Silva Junior, relataram em Juízo de forma firme, segura e em uma só voz que estávamos patrulhando pela área da Cracolândia, quando de longe, vimos eles caminhando, e ao nos verem, dispensaram algo, era um pacote de pão. Optamos pela abordagem dos dois, foi chamada uma guarda feminina, eles eram um casal. Com ela foram encontradas quatro porções de maconha. Com o réu nada foi encontrado, porém recuperada a sacola que eles dispensaram, foram encontradas as drogas. Eles estavam também com dinheiro e celulares. Reconheceram os réus e não os conheciam anteriormente. O réu confessou a comercialização do entorpecente, e que o dinheiro era proveniente da venda. A ré disse que era usuária.

Os guardas civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de patrulhamento de rotina pela região da Cracolândia, a suspeita dos réus que passavam juntos pelo fluxo e Gabriel ao visualizar os GCMs dispensou uma sacola, suas abordagens, o encontro das drogas na sacola, dinheiro e celulares em poder de ambos, e o momento em que a ré retira da região íntima quatro papelotes de maconha, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ª T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Neste contexto, em vista da variedade de drogas encontradas em poder do réu GABRIEL, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inesoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar a acusada da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase a ré BRUNA é primária e não ostenta antecedentes criminais, e ainda confessou que trazia drogas para seu uso.

Assim com relação a ela, aplico a pena de advertência, já aplicada em audiência.

Por sua vez, o réu GABRIEL é reincidente específico, conforme certidão de fls. 69, mas de outra banda confessou a autoria delitiva, motivo pelo qual mantenho a pena base por entender que tais circunstâncias se compensam, perfazendo, 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa

preponderante sobre a confissão. Ocorre porém que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual.

Não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 para o réu GABRIEL, tendo em vista que o condenado, é reincidente específico, foi detido em local conhecido como ponto de venda de drogas, com grande quantidade de drogas, circunstâncias estas suficientes a afastarem os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “ O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida – 13 (treze) pedras de crack – justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). Pelo mesmo motivo, incogitável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico, tendo em vista circunstância judicial desfavorável atinente à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (TJESP, Apelação Criminal nº 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO; STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e 141.921/SP), porquanto o expressivo (e variado) “carregamento” denota estreita vinculação do réu com organização destinada ao tráfico.

O valor do dia multa será o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar GABRIEL PINHEIRO DO AMARAL, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime fechado, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; opero ainda a desclassificação com relação à denunciada BRUNA FERNANDA PEREIRA, da imputação do artigo 33, para o artigo 28, ambos da Lei nº11.343/06, e em consequência aplico a pena de advertência, prevista no inciso I do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O condenado GABRIEL iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade fechado, pois além da reincidência, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado. Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau.

Não é possível também a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: “Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só

pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal. Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso e assim deve permanecer, pois foi nesta data condenado a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06. A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem. Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo ao condenado GABRIEL o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos

fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime - improvimento dos demais recursos."

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, bem como a perda do dinheiro apreendido à União.

Expeça-se termo de advertência, já saindo nesta oportunidade a condenada BRUNA advertida nos termos da sentença.

Expeça-se alvará de soltura clausulado com relação a BRUNA FERNANDA PEREIRA.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA